07 筆記：構成要件錯誤（續）、因果歷程偏離、違法性與容許構成要件錯誤

前堂回顧——雙重具體化錯誤

- 行為人與被害人**未面對面** → 難以區分客體錯誤或打擊錯誤
- 判斷公式：結果作用方式是否符合行為人對**因果鏈的設定**（許玉秀老師）

汽車炸彈案（政大轉學考）

- 甲在 A 車裝炸彈 → B 來開車被炸死 → A 在大樓頂樓被震波震落也死

被害人	死亡方式	是否符合因果鏈設定	錯誤類型	結論
B	發動車輛 → 被炸死	✔ 符合	**客體錯誤**	故意殺人既遂
A	震波震落 → 墜樓撞引擎蓋	✘ 不符合	**打擊錯誤**	頂多論過失

- 德國亦有打擊錯誤說（維安人員擋子彈案類比）
- 國內主流仍為**客體錯誤說**

構成要件選擇要素

一、定義

- 條文中用「或」連接的多個要素，符合**任**一即該當構成要件
- 例：§306 放火罪——住宅／建築物／附連圍繞土地／船艦（四擇一）
- 例：§195 偽造貨幣罪——貨幣／紙幣／銀行券（三擇一）

二、立法理由

- **語言困難**：找不到共同上位概念來涵蓋所有對象，只好一一列舉

三、菊島之星案例

- 客觀上侵入的是「建築物」，主觀以為侵入「船艦」
- 屬於選擇要素之間的錯誤

四、兩種類型的選擇要素

類型	特徵	舉例	錯誤效果
語言困難的選擇要素	各要素法律評價相等	§306（住宅/建築物/船艦）	不阻卻故意
立法經濟的選擇要素	各要素法律評價不相等	重傷罪§10④各款	回歸一般錯誤論（想像的→未遂＋實際的→過失）

排他互斥構成要件錯誤

一、問題所在

- 排他互斥構成要件產生三大問題：**構成要件錯誤**、**共犯踰越**、**事實不明**

二、典型案例

案例	互斥條文	情境
放火罪	§173（現有人）vs §174（現未有人）	以為廢棄工廠無人→放火→流浪漢逃出
墮胎罪	§289（受囑託）vs §291（未受囑託）	行為人對是否受囑託認知錯誤
性交猥褻罪	§227①（未滿14）vs §227③（14以上未滿16）	對被害人年齡認知錯誤

三、蔡聖偉老師的解法——透過解釋把互斥變包含

1. 找出**建構不法的要素 P** 和 **非建構不法的要素 non-P**
2. P（有人／未受囑託）= 加重要素 → 較重條文 = **加重犯**
3. non-P（無人／受囑託）= 非不法要素 → 較輕條文 = **基本犯**
4. 結果：**至少可論基本犯**

- §227 的處理：§3（14以上未滿16）= 基本犯，§1（未滿14）= 加重犯

- 共犯踰越問題 → 至少可論 §3 的教唆犯

> **注意**：「所知所犯」（唐律公式）已過時，不要採用

因果歷程偏離

一、定義

- 行為人實現犯罪結果，但實際過程與想像有差異

二、不重要的偏差

- 細節性偏差 → **不認為是偏離**，不影響故意認定
- 例：刺胸腔→刺脖子、傷肝→傷腎

三、一般的因果歷程偏離

- 用**客觀歸責**處理
- 救護車車禍案：行為人刺傷被害人→救護車途中車禍→被害人死亡
    - 結果不可歸責給行為人的刺傷行為 → 論**未遂**

四、故意對因果歷程的認知——三說

學說	內容	評價
重要性理論	認知重要部分即可	標準模糊，少採
否定說	因果歷程非故意認識對象	少採
風險認識說（蔡聖偉／許玉秀）	行為人對客觀上所製造的風險有認知→有故意	**多數說**

五、蘑菇案（北大法律所考過）

- 行為人以為蘑菇對幼童有毒性 → 實際上蘑菇是壞掉的 → 小孩吃壞蘑菇死亡
- 客觀風險 = 壞蘑菇致死；行為人**未認知**此風險 → 阻卻故意
- 分論：
    - **未遂**：想像中蘑菇毒性致死（未實現）
    - **過失**：實際壞蘑菇致死
    - → **§55 想像競合**

六、放火案（110年律師高考，周漾儀老師出題）

- 行為人放火燒被害人住宅，腦中只想像被害人被烈火焚燒而死
- 實際上被害人被火逼到頂樓→跳樓逃生失敗→墜地而死
- 通說：因果歷程**不反常**，屬不重要的偏差 → **故意殺人既遂**

> 周漾儀老師的「主觀規則理論」為臺大刑法組考點，國考不需使用

結果提前發生

一、定義

- 犯罪結果實現的時間比行為人想像的**更早**

二、與事前故意非故意的關係

- 結果在**著手前**實現 → **事前故意非故意** → 行為人頂多論**過失犯**
    - 例：下午保養手槍→槍枝走火→子彈穿門板打死鄰居 → 保養階段非殺人行為 → 無殺人故意
- 爭點：結果在**著手後**實現，是否一定論故意既遂？

三、各說比較

學說	標準	案例三（瞄準走火）	案例四（下毒5次，第2次死）

著手標準說（通說）	著手後 → 故意既遂	故意既遂	故意既遂
計畫完成標準說／主觀決定說（少數說）	行為人須覺得「該做的都做了，回不了頭」	分論未遂＋過失	分論未遂＋過失
典型構成要件行為標準說（許恆達老師）	客觀：須達典型構成要件行為；主觀：須有未必故意	瞄準非典型行為→分論未遂＋過失	下毒是典型行為→故意既遂

- 計畫完成標準說最嚴格（對行為人最有利），著手標準說最寬鬆
- 典型構成要件行為標準說介於兩者之間（臺大法研所考過）

結果延後發生

一、定義

- 犯罪結果實現的時間比行為人想像的**更晚**

二、典型案例——告白案（電影《告白》／花蓮實際案件）

- 高中生用電擊機關玩偶電擊班導女兒 → 以為女童已死 → 丟入泳池「棄屍」
- 實際上女童只被電暈 → 溺水而死

三、各說比較

學說	立場	結論
第一行為關鍵說（通說）	人怎麼死不重要，不重要的偏差	**故意殺人既遂**
區分處理說／數罪併罰說	風險未實現 → 前後分開評價	殺人未遂＋（棄屍未遂＋過失致死）想像競合 → 數罪併罰
概括故意說（歷史說法）	前後行為同一故意	殺人既遂（已無人採）

> 概括故意說混淆了「故意」與「犯罪計畫」的差異 → 後段棄屍階段行為人認為對方是屍體，根本無殺人故意

四、解題定位

類型	爭點核心	三階論位置
結果提前發生	行為人有無故意	放在**主觀**（主觀構成要件）
結果延後發生	風險有無實現	放在**客觀**（客觀歸責—風險實現）

違法性

一、違法性的功能

- 判斷行為**正當或不正當**
- 構成要件該當 → **推定違法**（經驗上通常不正當）

二、阻卻違法事由的來源

類型	說明	有無違反罪刑法定
法規阻卻違法事由	法律明文規定（正當防衛、緊急避難等）	無
超法規阻卻違法事由	法律未規定，但事理上承認	無（多一條無罪空間，對行為人有利）

三、可罰的違法性

（一）日本學說——肯定說

- 被害法益**輕微** ＋ 行為與社會相當程度**輕微** → 欠缺可罰的違法性 → **不成立犯罪**
- 兩個都要輕：偷吃一顆荔枝 ✔、亮刀搶一張白紙 ✘（行為不輕）
- 實務：74臺上4225判例使用「實質違法性」一詞，實際在講可罰的違法性（掛羊頭賣狗肉）

（二）德國學說——否定說

- **違法**只有「有」和「沒有」，無程度問題
- 有程度高低的是「**不法**」（民事不法＜行政不法＜刑事不法）
- 可罰的違法性混淆了違法與不法的概念
- 法益侵害量低 → 中心量刑或程序上緩起訴，非犯罪成立的問題

（三）考題案例（東吳轉學考）

- 甲未經同意取用路邊機車行水龍頭的水＋一小搓洗衣粉洗手
    - 肯定說：欠缺可罰的違法性 → 不成立犯罪
    - 否定說：犯罪成立，但屬情節量刑或程序處理問題

違法性的判斷——主客觀合致

阻卻違法三格子

前提事實	手段適當	主觀認知	結果
✔	✔	✔	阻卻違法
任一 ✘	—	—	不能阻卻違法

兩類錯誤

情形	名稱	案例
客觀欠缺＋主觀具備	**容許構成要件錯誤**（誤想防衛）	以為路人要猥褻→踹他一腳→其實只是提醒後背包
客觀具備＋主觀欠缺	**反面容許構成要件錯誤**（偶然避難）	基於報復砸仇人窗戶→恰好仇人家瓦斯外洩→反救全家

對應原理在違法性的適用（法研所考點）

- 客觀實現 A 阻卻違法事由，主觀出於 B 阻卻違法事由的意思
- 案例：A 實為現行犯可逮捕（合法逮捕），但 A 主觀以為在行使自助行為（民法§151）
- **連接理論**：要對應才能阻卻違法
- **累加理論**（蔡聖偉老師採）：不需對應 → A客觀＋B主觀 = **可阻卻違法**

> 理由：在違法性層面，「沒有阻卻違法事由」是反面判斷，不可能要求行為人認知到「什麼樣的沒有」→ 對應原理在違法性不適用（黑咖啡不加鮮奶油 vs 不加熱牛奶的比喻）

容許構成要件錯誤——五說

前提案例

- 晚上回家路上，路人靠近想提醒我後揹包拉鍊沒拉
- 我以為路人要猥褻我 → 踹他一腳 → 構成傷害罪
- 客觀上不存在正當防衛前提（無現在不法侵害）
- 主觀上以為侵害存在

各說比較

學說	體系背景	核心想法	效果
①故意理論	古典犯罪體系（故意在罪責）	不法意識欠缺→阻卻故意	阻卻故意→改論過失
②嚴格罪責理論	現代犯罪體系	不法意識欠缺→適用§16	可避免→減輕；不可避免→無罪
③限制罪責理論	現代犯罪體系（德國流行）	類推適用構成要件錯誤	阻卻故意→改論過失
④限制法律效果的罪責理論（通說）	現代犯罪體系	提出「罪責故意」概念→欠缺良知非難	阻卻罪責故意→改論過失
⑤負面構成要件理論	二階論	故意須認知「無阻卻違法事由」→主觀對此無認知	阻卻故意→改論過失

重點整理

- 大部分學說結論 = **阻卻故意，視情況改論過失犯**
- **唯一例外**：嚴格罪責理論 → 用 §16 處理（可避免→減輕，不可避免→無罪）
- **限制罪責理論**在德國流行但與我國水土不服（類推適用對象為德國刑法§16①，我國無對應規定）
- **限制法律效果的罪責理論**為國內通說：
    - 「罪責故意」= 看行為人良知是否值得譴責 = 有無想跟法律敵對的意思
    - 量身打造給容許構成要件錯誤使用
- **二階論**：構成要件＋違法性合併為「不法」（正面＋負面不法事實），故意範圍擴大 → 本來就得出正確結論

故意理論 vs 嚴格罪責理論的差異

- 兩者本質相同：都認為容許構成要件錯誤 = **不法意識欠缺**
- 差異在於搭配的三階論版本不同：
    - 古典體系：故意含不法意識→欠缺不法意識→阻卻故意
    - 現代體系：不法意識是獨立罪責要素→欠缺不法意識→適用§16
- 共同致命傷：容許構成要件錯誤是**事實誤認**，非法規範誤解，不符§16「不知法律」的要件

誤想防衛過當

- 誤想防衛如果手段過當 → 仍可適用（或類推適用）防衛過當或避難過當的規定

本堂重點提示

- **構成要件錯誤**的各類型已全部講完（選擇要素→排他互斥→因果歷程偏離→提前/延後發生）
- **違法性**的基礎概念（推定違法、阻卻違法事由來源、可罰違法性）
- **容許構成要件錯誤**五說為本堂最重要考點
- 下堂課預告：反面容許構成要件錯誤